

1502927-71.2021.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/01/2022
... 208/273 e RT 530/272.
Ainda:

TRÁFICO DE DROGAS. Alegação acerca de insuficiência de provas. Desacolhimento. Hipótese na qual são sólidos os demonstrativos a respeito da imputada traficância. Depoimentos de policiais civis que, prestados sob o crivo do contraditório, são suficientes a embasar édito condenatório. Laudos decorrentes de perícia que são de consideração. Assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santos
Foro de Santos
5ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502927-71.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502927-71.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PHELIPE SALDANHA BATISTA RODRIGUES

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Vistos.

PHELIPE SALDANHA BATISTA RODRIGUES foi preso em flagrante delito e denunciado pela prática, em tese, do crime de furto qualificado (artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal), porque no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 21h40min, na Rua General Câmara, nº 103, nesta Comarca, porque teria subtraído, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 18 maços de cigarros sem lacre, um alicate de corte, uma serra manual, uma furadeira vermelha Black e Decker e uma portinha de alumínio preto, subtraídos da empresa R. S. R. S. (págs. 88/92). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (págs. 62/65). A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2021, por preencher os requisitos legais e estar alicerçada em indícios de autoria, com os testemunhos de A.F.A. (pág. 07) e B.L.F.N. (pág. 05) e a materialidade provada pelo auto de exibição, apreensão e entrega da res furtiva às págs.11/12 (págs. 93/94). Citado (pág. 134), o réu apresentou resposta à acusação, aduzindo inocência e

pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça (pág. 139).

Foram negadas a absolvição sumária e a extinção de punibilidade, mas a gratuidade de justiça foi concedida ao acusado (pág. 141).

Em audiência de instrução e julgamento no modo virtual, foram coletados os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação. Posteriormente, o interrogatório do acusado. Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado. A Defesa, requereu a conversão dos debates orais em memoriais após a juntada do laudo pericial faltante (págs. 169/171).

Apresentado o laudo, a Defesa encartou seus memoriais a págs. 194/199 pleiteando a improcedência e, subsidiariamente, pena mínima, afastamento de qualificadora, reconhecimento da tentativa, benefícios legais e imposição de regime diverso do fechado, direito de recorrer em liberdade e afastamento do valor mínimo à reparação do dano.

É o relatório.

Passo a fundamentação e decido.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento do crime de furto qualificado, por rompimento de obstáculo e escalada, que vem assim previsto no Código Penal:

“Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

(...)

Furto qualificado

§ 4.º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é cometido:

I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III – com emprego de chave falsa;

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas.”

A ação é procedente em parte.

A materialidade do delito vem descrita por meio do boletim de ocorrência de págs. 02/04 e do auto de exibição, apreensão e entrega (págs. 11/12) e pelos depoimentos coletados.

Ao analisar o conjunto probatório produzido, inegável que a autoria recai sobre o réu.

A vítima informa, em audiência, ser sócio participante da loja em reforma onde estava encostada a escada com a grade e janela da sacada no 2º piso rompida. Disse que foi informado pelo dono do imóvel alugado que foi avisado pela polícia do ocorrido. Lá chegando, foi informado que haviam encontrado alguns pertences com o acusado e, ao chegar na delegacia, reconheceu os cigarros, as ferramentas apresentadas e o pequeno portão de alumínio que fechava o registro de água do local como pertencentes à loja. Comentou que recuperou todos os objetos furtados, mas que o mais oneroso foi o valor para reparar o dano causado pelo rompimento da janela e porta frontal. Disse que à época do ocorrido não havia câmeras no local e que a perícia compareceu, no dia, para averiguação.

Acerca dos fatos, ambos os policiais militares confirmam os termos da denúncia, narrando, de forma uníssona, que se recordam do ocorrido, estavam de patrulhamento de rotina e ao adentrarem na referida rua avistaram uma escada encostada dando acesso à uma sacada onde uma janela estava aberta. Na mesma rua, quase na esquina, avistaram o acusado e, ao abordarem, encontraram com ele uma sacola com as ferramentas, os cigarros e um portão de alumínio. Disseram que o acusado confessou ter retirado do local em que se encontrava a escada e que ele mesmo teria encontrado a escada próximo de lá. Ambos reconheceram o acusado, apesar de estar sem barba no dia da audiência, como sendo o detido no dia dos fatos.

A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se

vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação.
Nesse sentido, registrem-se os seguintes precedentes:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrim/SP - JUTACRIM 30/221).

"É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (TacrimSP - RT 530/372).

"PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador."

(Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência."

(HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

Na mesma direção:

"A condição de a testemunha ser Policial não a torna impedida ou suspeita para depor, devendo-se conferir à sua palavra a necessária credibilidade, decorrente da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (RJTACRIM 48/228).

Também: JTJ-Lex 200/276, 204/287, 205/314, 207/297, 208/273 e RT 530/272.
Ainda:

TRÁFICO DE DROGAS. Alegação acerca de insuficiência de provas. Desacolhimento. Hipótese na qual são sólidos os demonstrativos a respeito da imputada traficância. Depoimentos de policiais civis que, prestados sob o crivo do contraditório, são suficientes a embasar édito condenatório. Laudos decorrentes de perícia que são de consideração. Assim, condenação correspondente que se mantém. No mais, pena

corretamente dosada e individualizada. Logo, recurso improvido. (TJSP – Apel. nº 0001623-53.2013.8.26.0549 – 15ª Câm. Dir. Crim. – Rel. Des. Encinas Manfré – J. em 13/11/2014)

TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 4,3 gramas de maconha, 15,4 gramas de cocaína em forma de 50 pedras de "crack" e 24,5 gramas de cocaína em 34 porções. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão judicial somada aos depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga. Validade. Suficiência para a procedência da ação penal. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Impossibilidade de diminuição abaixo desse limite. Inteligência da súmula n 231 do STJ. Inadmissibilidade da redução que se justifica, ademais, por razões de segurança jurídica e para a observância dos princípios da isonomia, da individualização da pena e da separação de Poderes. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP – Apel. nº 0079402-29.2013.8.26.0050 – 16ª Câm. Dir. Crim. – Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo – J. em 18/11/2014)

Em interrogatório, o réu negou a prática do delito e disse que estava em situação de rua há 5 meses em uso de drogas. Disse que, no dia do ocorrido, a sacola que ele estava continha um teclado de computador velho para reciclagem, latinhas e que o portão de alumínio ele havia encontrado na rua. Disse que os policiais acharam uma sacola preta, contendo as ferramentas e cigarros perto da escada que estava apoiada na varanda da loja. Disse que foi levado à delegacia, não prestou depoimento e que o delegado o fez assinar um papel. Em seguida foi levado para o CDP. Disse que estava sendo julgado por ser reincidente e possuir passagem por furto. No entanto, as provas nos autos não sustentam a versão do réu, haja vista as declarações da vítima e os depoimentos policiais.

Não é demais dizer que o réu foi preso em flagrante, fato que, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

Dessa forma, a prova nos autos é firme no sentido de demonstrar que o acusado é o autor do furto, permitindo-se sua responsabilização.

Evidentes os requisitos concernentes à presença da autoria e materialidade do delito, resta apenas a análise das qualificadoras.

Nesse aspecto, restou demonstrado que o acesso ao interior do estabelecimento deu-se mediante escalada, apenas.

A escalada, como se sabe, estará configurada quando o sujeito ativo do delito se utiliza de via anormal para a subtração da res; o que se constatou no presente caso em virtude do uso da escada.

Nesse sentido, ensina Guilherme Nucci (in CP Comentado, 5 ed, RT, p. 630/631):

"Escalar implica em subir ou galgar, como regra. Portanto, torna-se fundamental que o sujeito suba a algum ponto mais alto do que o seu caminho natural, ou seja, é o ingresso anormal de alguém em algum lugar, implicando em acesso por aclave"

No que toca ao rompimento de obstáculo, tem exortado a doutrina que esta qualificadora é configurada apenas quando o citado obstáculo é externo e destinado precipuamente à proteção da res.

Assim sendo, seu reconhecimento deve ser pautado em absoluta certeza probatória de que, realmente, o obstáculo referido se prestava, efetivamente, à proteção da res,

sendo, inclusive, exterior a ela, o que não ficou demonstrado no presente caso pelo teor não conclusivo do laudo pericial.

Notório, ainda, que o agente percorreu todo o iter criminis, pois já estava com a posse dos bens e foi surpreendido no momento de sua fuga do local, após ter utilizado de escada para a escalada e subtraído para si os objetos em questão. Impõe-se, pois, a condenação do réu, nos termos acima expostos.

Passo, então, à dosimetria da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, observado o critério trifásico.

Em fundamentação à aplicação das penas, observo que os motivos, a personalidade do agente, a conduta social e a consequências do crime não são especialmente reprováveis. A culpabilidade da conduta também já foi mensurada no estabelecimento dos parâmetros abstratos de pena no tipo penal incriminador.

Haja vista o réu possuir 05 condenações criminais, inclusive específicas, transitadas em julgado antes do fato (págs. 19/27), e sabendo que o período depurador somente serve para fins de consideração de reincidência, não se aplicando aos maus antecedentes, que podem ser considerados a despeito de qualquer marco temporal, razoável majoração da pena-base em 1/3, estatuinto-a em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Em exclusão, a condenação mais recente (1502395-39.2017 - págs. 22/23) será utilizada para fins de reincidência. Existe também condenação por consumo de drogas (1501945-18.2017 - pág. 26) que, segundo o entendimento jurisprudencial, não pode ser utilizado para fins de agravamento da pena.

Na segunda fase do sistema trifásico, incide a agravante da reincidência específica a ser considerada pela condenação em 2018 no processo 1502395-39.2017.8.26.0536, acarretando novo aumento, agora em 1/6.

Com isso, a pena restará em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Ainda, tratando-se do cometimento do crime durante o estado de pandemia e calamidade pública declarado (artigo 31, inciso II, alínea "j", do Código Penal), é mais uma hipótese de agravante.

Em primeiro ponto, despicienda a demonstração de norma municipal para tal critério, considerando que existe reconhecimento de nível federal pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, como citado pelo Ministério Público e que tem incidência em todo o solo nacional.

Além disso, como é notório, a pandemia implicou em período de distanciamento social, restrições na locomoção geral e acesso a locais fechados por amplo lapso de tempo, o que gerou menor circulação de pessoas em vias públicas.

Este cenário é certamente favorável à prática de crimes como o presente, com escalada para a retirada de bens que não lhe pertencem. Com tal utilidade, justifica-se maior reprimenda na pena, eis que se aproveita de peculiar e grave situação social com o objetivo de enriquecimento pessoal ilícito.

Sendo assim, majoro a pena em 1/6, resultando a pena intermediária em 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo por que a pena será a acima fixada.

Dada a quantidade de pena impingida, reincidência específica e o teor da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, o regime inicial de pena será o semiaberto, adequada à gravidade do fato praticado e as múltiplas condenações do réu.

E, sendo reincidente, incabível a substituição da pena por restritivas de direitos (artigo 44, II, Código Penal), certo de que já foi condenado pelo crime de furto no passado e, pela diversidade de outras condenações, ser a medida não socialmente recomendável, tenho que incabível a aplicação do §3º do Código Penal. Em igualdade, inaplicável a substituição da pena (artigo 77, I, Código Penal).

Dispositivo.

Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para condenar o réu PHELIPE SALDANHA BATISTA RODRIGUES, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, às seguintes penas: 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 17

(dezessete) dias-multa, nos valores mínimos legais.

Considerando o tempo preso preventivamente, verifica-se que ainda não seria cumprido o marco para progressão de regime, na forma do artigo 112, II, da Lei de Execuções Penais, de modo que deixo de aplicar a detração da pena (§2º do artigo 387 do Código de Processo Penal).

Outrossim, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, por não ter sido constatado o arrombamento e prejuízo concreto no caso, sobretudo pela apreensão dos bens.

Por fim, considerando a fixação do regime inicial semiaberto, além do tempo de prisão cautelar experimentado – suficiente para acautelar a ordem pública abalada pelo delito, de rigor a concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto manter a prisão preventiva, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representaria a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele ora estabelecido.

Nesse sentido, destaca-se que, em julgados recentes, o E. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se considerou ser a prisão preventiva incompatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTES SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 185181 AgR, Relator(a): Min. CÂRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)

HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES ADEQUAÇÃO. Ausente demonstração de dedicação do paciente a atividades criminosas, surge adequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTO TÍTULO CONDENATÓRIO REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A previsão do regime semiaberto para o cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva, cujo cumprimento dá-se no fechado, implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a do título condenatório. (HC 180016, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020) (grifei)

APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma tentada. Recursos defensivos. Preliminar de nulidade. Violação ao princípio da individualização da pena. Inadmissibilidade. Sistema trifásico devidamente observado em favor do acusado MAICON. Preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade bem demonstradas. Réus confessos. Dosimetria. Pleito de redução da fração de diminuição relativa ao reconhecimento da forma tentada do delito. Possibilidade. Acusados que percorreram iter criminis intermediário. Pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Cabimento. Arma apreendida que estava desmuniada. Ausência de potencial lesivo. Penas redimensionadas. Abrandamento do regime prisional fixado em desfavor dos apelantes. Cabível. Quantum da pena e demais circunstâncias do delito que autorizam a fixação do regime inicial aberto aos acusados MAICON e ÍTALO, e do regime inicial semiaberto ao apelante CARLOS, em razão da reincidência por ele ostentada. Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Revogação da prisão preventiva dos apelantes. Regimes prisionais fixados incompatíveis com a prisão preventiva. Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal. Recursos parcialmente providos.

(TJSP; Apelação Criminal 1500054-83.2021.8.26.0153; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data

do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021) (grifei)

Assim sendo, REVOGO a prisão preventiva do réu, autorizando o recurso em liberdade (artigo 387, §1º, do Código Penal). Expeça-se alvará de soltura clausulado. Com o trânsito em julgado, providencie o necessário para cumprimento e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Santos, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA